

1500369-29.2022.8.26.0557

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDERSON VALENTE

Comarca: Guaíra

Foro: Foro de Guaíra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 03/11/2022

... é equiparado aos hediondos.

O crime de tráfico de entorpecentes é equiparado aos delitos hediondos, portanto os mais graves dentre os elencados no Código Penal e em Leis Especiais.

Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas.

Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são tidos como hediondos, como, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaíra

Foro de Guaíra

1ª Vara

Av. 17, 414, Guaíra - SP - cep 14790-000

1500369-29.2022.8.26.0557 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500369-29.2022.8.26.0557

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Natália Augusta da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON VALENTE

Vistos.

I. NATÁLIA AUGUSTA DA SILVA, qualificada nos autos a fls. 20, foi denunciada e viu-se processada como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 17 de junho de 2022, por volta de 22h44min, na Avenida 27 nº 1.587, Bairro Miguel Fabiano, nesta cidade e Comarca de Guaíra, teria trazido consigo e teria em depósito, para fins de tráfico, doze porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 1,68 g, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que “na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos quando avistaram a denunciada, conhecida nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas, entregando algo para um suposto usuário.

Diante das circunstâncias, os policiais se aproximaram e abordaram a denunciada, vindo a apreender em seu poder dois pinos com 'cocaína', além de R\$ 85,00 em dinheiro. Ainda, com o suposto usuário, apreenderam outros dois pinos contendo 'cocaína'.

Em seguida, a cerca de 20 metros de onde a denunciado foi abordada, os policiais localizaram e apreenderam mais 10 pinos idênticos aos apreendidos em poder de NATÁLIA.”.

A denúncia de fls. 133/134 foi recebida em 19 de julho de 2022 (fls. 135). A Ré foi citada (fls. 141) e apresentou defesa preliminar em fls. 155/158, rejeitada a fls. 160/161. Na instrução da causa foi colhida prova oral e interrogada a Acusada (fls. 229).

Em memoriais, o ilustre representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia (fls. 227/228).

A douta Defesa, por seu turno, a fls. 230/231, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão e que se observe a disposição do artigo 42 da Lei 11.343/06, impondo-lhe regime de cumprimento de pena menos grave ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

II. Fundamento e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está estampada no auto de prisão em flagrante de fls. 01/06, no boletim de ocorrência de fls. 09/11, auto de exibição e apreensão de fls. 12, auto de constatação preliminar de fls. 14/16, pelo laudo de exame químico-toxicológico a fls. 49/50, comprovante de depósito de fls. 121, além da prova oral colhida durante a instrução.

A autoria é certa contra a Ré que na fase inquisitorial laconicamente se limitou a dizer que o entorpecente não era seu (fls. 05), ao passo que em Juízo confessou a prática do crime, dizendo que é usuária de crack, comercializava entorpecente para sustentar seu vício e na data dos fatos vendeu a droga para Jean, cobrando R\$ 5,00, sendo com ela encontrado, pelos policiais, mais duas porções de cocaína, além de um cachimbo e uma pedra de crack, que iria consumir, mas esses objetos foram destruídos na abordagem. Ademais, não tem ocupação, às vezes se prostitui e o restante da droga apreendida não era dela.

A testemunha Jean declarou em Juízo que na data dos fatos foi comprar cerveja quando encontrou a Ré, que lhe ofereceu cocaína, e dela adquirindo duas porções por R\$ 10,00 ou R\$ 15,00, instante em que fora abordado por policiais no momento em que recebia da Acusada a droga, sendo que já carregava consigo um pino do mesmo

entorpecente, adquirido anteriormente de outra pessoa, dizendo, ainda, que fora a primeira vez que adquiriu entorpecente da Ré.

O policial militar Deivid, também em fase judicial, afirmou que estava em patrulhamento pelo local dos fatos visando coibir a prática, ali, do tráfico, sendo que avistou a Ré entregando droga para Jean e este, então, saiu com sua bicicleta, sendo abordado à frente carregando duas porções de cocaína, dizendo tê-la adquirido da Acusada, ao passo que o depoente prendeu a Ré, que trazia consigo dois eppendorfs da mesma substância e dinheiro, sendo que perto localizaram o restante da droga, idêntica, escondida. A Ré optou pelo silêncio e é conhecida dos meios policiais pela prática de outros crimes e recentemente pelo tráfico, o que foi alertado inclusive por sua genitora, que contou que sua filha tinha pedido uma veste de baixo melhor porque a dela não estava escondendo a contento os eppendorfs. Por fim, a Acusada não aparentava estar sob efeito de droga.

A conduta da Acusada, pois, indica que no dia, horário e local apontados na denúncia, trazia consigo e tinha em depósito substância entorpecente para fins de traficância. A isso se chega com a prova coligida aos autos, notadamente a visualização pelos policiais dela entregando o entorpecente para Jean, que confirmou que havia da Ré adquirido droga, assim como o dinheiro apreendido sem origem lícita declarada e o fato dela ser conhecida dos meios policiais pela traficância, não podendo se ignorar, outrossim, que o local é notório ponto de venda de drogas e a Acusada não estava sob efeito de entorpecentes, vindo, inclusive, a confessar a traficância. Tais condutas apontam que o Réu utilizava o entorpecente apreendido consigo para fins de mercantilização, consoante se extrai do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343, de 23.08.2006. Importante destacar que o simples fato de ser usuária de drogas – sequer comprovado – não inibiria a conduta do narcotráfico, sendo que, muitas vezes, tais condutas caminham juntas.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade da Acusada ou extingam sua punibilidade. Sendo assim, reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

A Acusada ostenta maus antecedentes, consistente em condenações criminais sem efeitos para reincidência (fls. 55, autos nº 0002238-27.2012.8.26.0210 e fls. 57/58, autos nº 0005752-90.2009.8.26.0210) e que podem ser utilizadas sem risco de incorrer em bis in idem com a reincidência porque são processos distintos, o que demonstra personalidade voltada para a prática de condutas antissociais e exige resposta estatal mais vigorosa, razão pela qual, atendendo aos critérios dos artigos 59 e 60 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06, com o que promovo o aumento da pena-base em 1/6 (um sexto) e a fixo em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no menor patamar, à míngua da comprovação de suas condições financeiras.

Na segunda fase da dosimetria da pena, aumento-a em 1/3 (um terço) em razão da tripla reincidência (cf. fls. 52/53, autos nº 0000897-24.2016.8.26.0210; fls. 53/54, autos nº 0001020-22.2016.8.26.0210 e fls. 54, autos nº 0001435-73.2014.8.26.0210), atingindo o patamar de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 777 (seiscentos e setenta e sete) dias-multa.

Por outro lado, ainda nesta segunda fase, necessário se mostra reconhecer a confissão espontânea, circunstância atenuante do artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, reduzindo sua pena em 1/6 (um sexto) e a fixando definitivamente em 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e ao pagamento de 647 (seiscentos e quarenta e sete) dias-multa, este em seu piso, posto que deve preponderar a multirreincidência sobre esta atenuante, com fundamento no artigo 67 do Código Penal, verbis: "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas

do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, 'a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada' (RH C 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli).

2. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual" (STF, HC 105.543/MS, 1ª T., Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26.05.2014).

A Acusada não faz jus à causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que a forma como se desenhou os fatos, sendo ela, portadora de péssimos antecedentes e reincidente, conhecida pela traficância, vem a demonstrar que se dedica, indubitavelmente, à atividade criminosa do tráfico de drogas, tanto que não demonstrou possuir ocupação lícita.

Nesse diapasão: "Para redução da pena, essencial que o réu seja 'primário', apresente 'bons antecedentes', comprove que 'não se dedique às atividades criminosas', assim como, 'nem integre organização criminosa'.

Evidente que essa causa de redução da pena está reservada àquele que age por um impulso, um desvio, em situação isolada no tráfico de drogas. E mais, os parâmetros para a graduação da redução (1/6 a 2/3) devem ser objetivos e extraídos das diversas circunstâncias que envolvam o caso concreto, podendo variar dentro do seu campo de incidência. Essa causa de redução da pena deve incidir na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia, estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder.

Ao julgador compete a análise do impulso, do fator determinante da conduta objetivamente tratada, que lhe permita concluir tratar-se mesmo de caso de um criminoso meramente ocasional, ou mesmo, se vem tomando aquela conduta como estilo de vida, para que possa, não apenas determinar a gradação da redução da pena, como até mesmo o total afastamento da causa de redução" (TJSP, Ap. 0003548-97.2014.8.26.0210, 3ª C.D.Crim., Rel. Des. Luiz Antonio Cardoso, j. 30.07.2019).

O regime de cumprimento de pena adequado, por se tratar de crime equiparado ao hediondo, é o inicial fechado. Nesse panorama: "O regime prisional inicial fechado foi fixado com absoluto acerto, não só por previsão legal artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07 como, também, pela gravidade do crime, de catastróficas consequências à saúde pública, e responsável, também, pela desagregação familiar e social. Tanto é que o delito é equiparado aos hediondos.

O crime de tráfico de entorpecentes é equiparado aos delitos hediondos, portanto os mais graves dentre os elencados no Código Penal e em Leis Especiais.

Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas.

Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são tidos como hediondos, como, por exemplo, o de roubo agravado, o de homicídio simples, dentre outros. Mesmo o tráfico de drogas, considerado o § 4º, do artigo 33 da respectiva Lei Especial, é, sem dúvida, crime grave.

Mas há os considerados hediondos.

Hediondo quer significar horrendo, gravíssimo, repulsivo, absolutamente intolerável.

Ora, sendo assim, como aplicar-se para um crime hediondo, como o tráfico de entorpecentes, regime que não o inicial fechado?

O traficante, perante a lei penal tal como está em vigor, é tido como um pária da sociedade, que destrói, não só a saúde das pessoas, especialmente a dos jovens, deixando muitos deles incapacitados para estudar ou mesmo trabalhar, pois é sabido que a cocaína e o 'crack', por exemplo, além de causarem dependência, destroem os neurônios, como ainda arrasam os patrimônios das famílias, com gastos desmesurados com tratamentos e internações, e o que é pior: com mínimas chances de recuperação. Bem por isso que se trata de crime hediondo.

A sociedade não tolera o traficante, não podendo o Poder Judiciário fazer ouvidos

moucos ao clamor social.

O legislador, com a edição da Lei nº 11.343/06, passou a punir o tráfico de forma mais severa exatamente porque o Poder Legislativo percebeu, sentiu que o tecido social estava se esgarçando cada vez mais e que os valores deveriam ser preservados.

Uma sociedade repleta de viciados e dependentes é uma sociedade que caminha a passos largos para sua própria destruição com o prejuízo de todos, menos dos traficantes que, com o dinheiro e patrimônio amealhados de forma criminosa, poderão deixar o País e mudarem-se para outros lugares, onde, com certeza, passarão a destroçar outras sociedades, outras inúmeras famílias.

Em suma, a sociedade e o Brasil como um todo é o que menos os preocupa" (TJSP, Ap. 0000555-39.2016.8.26.0557, 15ª C.D.Públ., Rel. Des. Poças Leitão, j. 01.02.2018).

Por outro lado, é vedada a concessão de sursis ou substituição por pena restritiva de direitos, pela ausência dos requisitos subjetivo e objetivo. Ressalto, quanto tal aspecto que, não obstante a decisão tomada no HC 97.256/RS, do STF, que não possui cunho vinculante, com a devida vênia, não se verifica compatibilidade lógica da pena restritiva com a natureza da infração, sendo que deveria a defesa fazer prova de que a Acusada possui condições da substituição da pena corporal, o que não é afastado nem mesmo diante da Resolução nº 5/2012 do Senado, não havendo que se falar em violação ao princípio da individualização da pena, porquanto esta deve se dar respeitando parâmetros preestabelecidos pela lei, notadamente porque o artigo 5º, inciso XLIII, da CF/88 determinou regime mais rigoroso na reprimenda de crimes hediondos e equiparados.

Relevo, ainda, que a disposição do artigo 44 do Código Penal, que trata da conversão de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não é de aplicação automática, pois elenca os requisitos legais para tanto. Ali, em seu inciso III, estabelece que somente é aplicável a comutação quando a conduta social do réu, além dos motivos e circunstâncias do delito, forem favoráveis. A simples prática do narcotráfico, este o flagelo de nossa sociedade, indica o sujeito ativo do crime como pessoa portadora de péssima conduta social, sendo que os motivos e circunstâncias do crime são, evidentemente, desfavoráveis. Para isso, basta se ter contato com um usuário de entorpecente para se verificar a miséria que se tornou sua existência (e de sua família), tão-somente pelo consumo daquilo que é oferecido pelo traficante (ainda que seja um "pequeno" traficante).

Para o crime de narcotráfico, circunstâncias como primariedade, bons antecedentes ou emprego lícito (sendo que a Ré não é possuidora de nenhum destes predicados) servem para fixar a pena aplicada, bem como, quando o caso, o critério redutor. Contudo, não viabilizam a conversão em pena restritiva ou mesmo a fixação em regime que não o fechado, em vista dos diplomas legais acima citados, pois insuficiente à repressão e prevenção desta infração equiparada à crime delito hediondo. Nesse sentido, lapidar excerto de acórdão do E. Tribunal de Justiça Bandeirante, verbis: "Ressalta-se que a decisão apresentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 111.840/ES, em 27 de junho de 2012, reconhecendo e declarando incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 tem seus efeitos 'restritos ao processo e às partes litigantes', não possuindo efeito 'erga omnes', até porque, não afastada pela Suprema Corte a natureza hedionda do delito de tráfico, justificando a imposição do regime mais gravoso, em respeito aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena. Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, possibilitando a imposição de regime fechado para o crime de tráfico de entorpecente: HABEAS CORPUS nº 189.960/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 16.08.2012; HABEAS CORPUS 216.265/SP. Rel. Min. Og Fernandes, DJe 02.06.2012; HABEAS CORPUS 199.619/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27.08.2012; e HABEAS CORPUS nº 225.568/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe. 27.08.2012.

Não há que se falar em conversão da pena privativa de liberdade por pena restritiva

de direitos, havendo a necessidade de pronunciar algumas considerações.

Com efeito, o Senado, na forma do artigo 52, inciso X da Constituição Federal e com olhos voltados para o julgamento do HC nº 97.256/RS, pelo Supremo Tribunal Federal, editou a Resolução nº 05/2012, cujo teor é a suspensão da parte que obstaculizava a conversão da pena privativa de liberdade em pena alternativa, inserida no parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

No entanto, com a devida vênia, o traficante, seja de pequeno, de médio ou de grande porte, não tem mérito para inicialmente cumprir a pena cominada de outra forma que não encarcerado.

Em vista o postulado implícito da proporcionalidade (HUMBERTO ÁVILA, Teoria dos Princípios, Ed. Malheiros), que é uma espécie de norma jurídica derivada do devido, justo e adequado processo legal (FAIR TRAIL), não se mostra razoável que o traficante, condenado por delito equiparado a hediondo (artigo 5º, inciso XLIII da Constituição Federal) venha a receber tratamento similar ao agente que perpetra um delito de menor potencial ofensivo.

Nesse contexto, pondera-se: de onde viria o numerário para o traficante cumprir a prestação pecuniária? E mais: onde o traficante, disseminador de vício, cumpriria prestação de serviços à comunidade ou entidade pública? Nas escolas? Nas creches? Nos orfanatos? Nos abrigos? Nos hospitais?

Em suma, não se mostra adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito em casos de tráfico de entorpecente, uma vez que tal medida atenta contra a efetividade do processo penal na aplicação do justo concreto, atingindo frontalmente o caráter retributivo da reprimenda e a dimensão material ou substancial do 'DUE PROCESS OF LAW'.

Além disso, é válido ressaltar que os recentes arestos do Colendo Superior Tribunal de Justiça indicam que não há ilegalidade na negativa de permuta, quando fundada na multiplicidade e na natureza lesiva das drogas apreendidas, isso porque a conversão da sanção reclusiva não seria suficiente para a prevenção e a repressão do delito denunciado (HC 204115 / MG - Ministro JORGE MUSSI - QUINTA TURMA - DJe 15/02/2012). E, na espécie, como foram apreendidas porções consideráveis de 'maconha', a aplicação de pena alternativa encontra óbice na exegese do artigo 44, inciso III, do Código Penal, sendo insuficiente como resposta à culpabilidade do agente, aos motivos e às consequências do exercício da atividade ilícita" (TJSP, Ap. 0005407-56.2011.8.26.0210, 4ª C.D.Crim., Rel. Des. Euvaldo Chaib, j. 18.12.2012).

Lado outro, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando o artigo 387, inciso IV, do CPP, com redação dada pela Lei 11.719, de 20.06.2008, porquanto o crime apurado é classificado como vago, assim entendido aquele que tem por sujeito passivo a sociedade, destacando, outrossim, que não se comprovou qualquer dano causado em sujeitos passivos secundários (pessoa submetida aos riscos da lesão).

À derradeira, tendo em vista que a Acusada foi condenada como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo com ela localizada quantia em dinheiro, evidenciando-se seu emprego na venda de drogas ilícitas, com fulcro no artigo 63, caput, do aludido diploma legal, decreto a perda dos valores apreendidos com a Ré, depositados em Juízo, que deverão ser encaminhados em favor da União, com o trânsito em julgado desta sentença (artigo 63, parágrafo 1º).

III. Isto posto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e, em consequência, CONDENO a Ré NATÁLIA AUGUSTA DA SILVA, qualificada nos autos, à pena de 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e ao pagamento de 647 (seiscentos e quarenta e sete) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, com correção monetária a partir do fato delituoso, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em regime inicial fechado, vedadas a substituição por pena restritiva de direitos ou concessão de sursis. No mais, decreto a perda do dinheiro apreendido com ela (cf. fls. 121), em favor da União.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) e encaminhem-se o numerário depositado em fls. 121 em favor da União.

Diante da pena aplicada, em regime inicial fechado em razão da equiparação à hediondez, por seus péssimos antecedentes e ainda por sua tripla reincidência, a Ré, descontente com a decisão, deverá aguardar o julgamento do recurso preso, mantendo, então, sua prisão cautelar, sem prejuízo da apelação, nos termos do artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal, pois nada justifica que, presa em flagrante, fosse colocada em liberdade depois de condenada.

São devidas custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Guaíra, 03 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA